

根据被告人供述，行为人主观上明知涉案牲畜是附近猪场的猪，为实现贪便宜的非法占有目的，行为人分工配合，对涉案牲畜围堵拦截，屠宰后分割。综合行为人的行为来看，其主观上并不具有事后返还财物的主观意愿，客观上也因牲畜被屠宰而确无返还可能。

（二）行为人通过实施一系列积极主动的行为，取得了对涉案牲畜的控制权

侵占罪成立的前提是行为人在侵占他人财物之前，必须已经实际持有或控制他人财物，方式限于代为保管他人财物、拾得他人的遗忘物及发现他人的埋藏物三种方式。而盗窃罪的行为人在实施盗窃他人财物时，并不具备实际持有或控制他人财物的前提条件。

案发当天，本案行为人并未实际控制或持有涉案牲畜，而是采用了分工配合，利用钢叉、木棍、放狗赶猪等撵猪、杀猪的一系列积极主动的行为，行为人非法占有他人财物的意图明显，数额较大，应以盗窃罪追究其刑事责任。

三、关于量刑

涉案养猪场曾多次有过猪跑出猪圈，蹀踏附近村民菜地的情形，养猪场主人并未采取相关措施避免此类行为的发生，而是采用放任的态度，置之不理，其对本案的发生也有一定的过错。

编写人：河南省平顶山市中级人民法院 宋红超 张顺强 孙梦蝶

油罐车驾驶员利用工作便利在运输途中 窃取油品构成盗窃罪

——左某等盗窃案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省杭州市中级人民法院(2022)浙01刑终335号刑事裁定书

2. 案由：盗窃罪

【基本案情】

2018年8月至2021年2月，被告人左某、左某1、崔某某与被告人莊某1、莊某某、魏某、刘某、沈某某等人分别结伙，利用被告人莊某1等人运输成品油的工作便利，在某村委会附近路段等地私自打开油罐车出油口，以桶装的形式窃取车内他人的成品油，再由被告人左某等人收购并出售牟利。其中，被告人左某1从2019年4月开始参与窃取成品油，并主要负责在某停车场等地销售；被告人崔某某受被告人左某雇用，从2020年9月开始参与窃取成品油，主要负责接油并运至被告人左某1处销售。

被告人左某、左某1、莊某1、魏某、刘某、莊某某对起诉书指控的罪名均无异议，认为本案应定性为职务侵占罪。被告人沈某某、崔某某对起诉书指控的事实及罪名均无异议。

被告人左某、左某1、莊某1、魏某、刘某、莊某某的辩护人提出本案中油罐车驾驶员的行为应认定为职务侵占罪，具体理由如下：驾驶员受运输公司雇用，工作期间经手的油品丢失、被盗等后果由运输公司对外承担，本案驾驶员

私卖的油品均是从未封铅的出油口放出的，说明托运人并未实际占有油品，运输过程中系由运输公司实际占有，应视为运输公司的财物，各驾驶员利用运输油品的职务便利，将本单位油品秘密窃为己有，符合职务侵占罪的构成要件。

【案件焦点】

本案应定性为职务侵占罪还是盗窃罪。

【法院裁判要旨】

浙江省杭州市萧山区人民法院经审理认为：被告人左某、左某1、崔某某与被告人莊某1、莊某某、魏某、刘某、沈某某等人分别结伙，以非法占有为目的，多次秘密窃取公私财物，其中被告人左某、左某1、莊某1属于数额特别巨大，被告人魏某、刘某、沈某某、莊某某、崔某某属于数额巨大，其行为均已构成盗窃罪，系共同犯罪。关于本案定性的问题，根据证人证言及运输协议等证据可以证实被告人莊某1、魏某、刘某、沈某某等人所运输的油品所有权为相关的用油公司，而非油品运输公司，油罐车的管理虽存在漏洞并未完全封铅，但并不意味着油品运输公司在运输途中即对油罐车中的油品具有支配权利，油品并未转移占有，故被告人莊某1、魏某、刘某、沈某某作为驾驶员自然也未占有案涉成品油，此外同案人曾某某所卖油品及被告人刘某所卖部分油品虽非油罐中的油品而是油罐车油箱内的油品，但油品运输公司并未授权驾驶员除自身车辆使用外支配油箱内油品的权利，故窃取油箱内油品的行为也非侵占行为，被告人莊某1、魏某、刘某、沈某某、莊某某的行为符合盗窃罪的构成要件。据此，判决如下：

一、以盗窃罪判处被告人左某犯盗窃罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金50000元；

二、判处被告人左某1犯盗窃罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金30000元；
30000元；

三、判处被告人莊某1犯盗窃罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金

30000元；

四、判处被告人魏某犯盗窃罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金20000元；

五、判处被告人刘某犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金20000元；

六、判处被告人沈某某犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金10000元；

七、判处被告人崔某某犯盗窃罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年二个月，并处罚金8000元；

八、判处被告人莊某某犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金5000元。

一审宣判后，左某、左某1、莊某1、魏某提出上诉。

浙江省杭州市中级人民法院经审理后同意一审法院裁判意见，并裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案的争议焦点即涉案油罐车驾驶员的行为性质认定问题，一种观点认为，本案被盗油罐内油品非油品运输公司财物，油罐车驾驶员窃取油品也未利用职务便利，油罐车驾驶员仅利用运输油品的工作便利窃取用油公司的油品，其行为构成盗窃罪。另一种观点认为，油品运输公司在运输途中对承运油品具有保管义务，公司驾驶员在工作期间经手的油品丢失、被盗等后果由油品运输公司对外承担，故可就此认定油品运输公司对承运油品已实际占有，油罐车驾驶员利用运输途中经手油品的职务便利窃取油品的行为构成职务侵占罪。笔者倾向于第一种观点。

盗窃罪与职务侵占罪均是以非法占有财物为目的，侵犯财产所有权的犯罪。从犯罪构成要件来看，两者的区别包含以下三个方面：(1)主体要件不同。盗窃罪是一般主体，职务侵占罪是特殊主体，即公司、企业或其他单位的人员。(2)犯罪对象不同。盗窃罪非法占有的对象可以是任何公私财物，而职务侵占罪侵占的对象只限于本单位且是本人经手、管理的财物。(3)犯罪手段不同。职务侵占罪侵占本单位财物的手段可以是盗窃、诈骗等多种，但均需利用职务

